

1500062-21.2022.8.26.0575

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: WYLDENSOR MARTINS SOARES

Comarca: São José do Rio Pardo

Foro: Foro de São José do Rio Pardo

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 19/05/2022

... a desclassificação do crime de tráfico para o de usuário. No que tange Amélio Ribeiro, alega que não tem nada a ver com o tráfico e nem com a arma encontrada na residência. Diante o exposto, a defesa requer a liberdade provisória do acusado Amélio Ribeiro, e pugna pela desclassificação do crime de tráfico para de usuário, em relação ao réu Amélio Filho. Apresentou ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Pardo

Foro de São José do Rio Pardo

1ª Vara

Praça dos Três Poderes, nº 3, Sao Jose do Rio Pardo-SP - cep 13720-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 18h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500062-21.2022.8.26.0575 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500062-21.2022.8.26.0575

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2028705/2022 - DEL.INV.GER. CASA BRANCA, 22755906 - DEL.INV.GER. CASA BRANCA, 7/22/212 - DEL.INV.GER. CASA BRANCA, 2028705 - DEL.INV.GER. CASA BRANCA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

AMELIO RIBEIRO e outro

Réu Preso

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). WYLDENSOR MARTINS SOARES

Vistos.

Trata-se de ação penal promovida em desfavor de Amélio Ribeiro Filho e Amélio Ribeiro, como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 e no artigo 12, "caput", da Lei nº 10.826/2003, na forma do artigo 69 do Código Penal, eis que no

dia 01 de fevereiro de 2022, por volta das 11h30, na Rua Guilherme Teo, nº 224, Santo Antonio, nesta cidade e comarca, vendiam, mantinham em depósito e guardava na residência deles, 126 (cento e vinte e seis) eppendorfs contendo cocaína e um invólucro plástico fechado por nó, contendo a mesma droga, tudo pesando 55,36g (cinquenta e cinco gramas e seis centigramas), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta, ainda, do incluso inquérito policial que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima descritas, Amélio Ribeiro Filho e Amélio Ribeiro, possuíam e mantinham sob sua guarda um revólver calibre 38, com numeração J103284, além de 30 cartuchos íntegros de calibre .38, da marca "CBC" e 43 cápsulas deflagradas deste mesmo calibre; o que fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia de págs. 158/161, veio acompanhada do Inquérito Policial - Prisão em Flagrante - de páginas 01/137.

Os réus apresentaram defesa preliminar (págs. 201/209), sustentando que o réu Amélio Filho assumiu ser o único proprietário da droga e do revólver. Alega que ele é usuário e não comerciante das drogas. Requer, portanto, a desclassificação do crime de tráfico para o de usuário. No que tange Amélio Ribeiro, alega que não tem nada a ver com o tráfico e nem com a arma encontrada na residência. Diante o exposto, a defesa requer a liberdade provisória do acusado Amélio Ribeiro, e pugna pela desclassificação do crime de tráfico para de usuário, em relação ao réu Amélio Filho. Apresentou rol de testemunhas.

A denúncia foi recebida aos 09 de março de 2022, determinando-se a citação dos réus e designando audiência de instrução, debates e julgamento (pág. 210/212).

Durante a solenidade de instrução, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes, bem como foi procedido ao interrogatório dos acusados, conforme termo acostado aos autos e mídia que se encontra arquivada no SAJ - pgs. 296/299.

Na fase do art. 402 do CPP nada foi requerido.

O Ministério Público manifestou-se contrariamente ao pedido de revogação da prisão preventiva de Amélio Ribeiro - pgs. 301/302.

Em memoriais, o Ministério Público requer a condenação de ambos os réus. Apresentou o resumo da prova oral coligida e concluiu que as testemunhas de defesa em nada socorreram os réus. Reputa evidente a tentativa de Amélio Filho em atrair exclusivamente para si as consequências do delito para proteger seu genitor e eximi-lo de sua responsabilidade penal. Alega ser inconcebível que Amélio (pai) não soubesse das drogas e munições que estavam em seu próprio quarto. Requer o aumento da pena base, pois ambos os réus possuem antecedentes criminais e diante da quantidade de drogas apreendidas. A quantidade de munições também é grande, o que justifica aumento de pena neste delito. Na segunda fase, Amélio Filho confessa, porém tentou eximir seu pai de culpa devendo ser a pena atenuada no mínimo possível. Requer o afastamento da causa de diminuição de pena, pois não são traficantes iniciantes e devem receber o regime inicial fechado - pgs. 303/313.

A Defesa, por sua vez, manifestou-se nas pgs. 315/335 requerendo a absolvição de

Amélio Ribeiro. Ressalta que Amélio Ribeiro Filho assumiu a propriedade das drogas, arma e munições. Invoca o benefício da dúvida. Argumenta que a prisão foi ilegal, pois o réu não estaria em situação de flagrante e sua casa foi invadida. A autorização de ingresso na residência foi negada pelo réu. Ressalta que Amélio Ribeiro é pessoa de 72 anos e nada indica que faça do tráfico seu meio de vida. Requer, ainda, a aplicação da atenuante do inciso I do art. 65 do Código Penal, diante da idade do réu - 73 anos. As testemunhas ouvidas disseram que Amélio Ribeiro sempre exerceu atividade remunerada e ficou provado nos autos que não tinha e não teve a posse ou guarda da arma apreendida. Em relação a Amélio Filho indica a confissão espontânea devendo gerar a necessária diminuição da pena. Pugna, ainda, pela minorante do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. Alega que o delito de posse de arma é atípico, crime impossível, pois a arma não estava municiada e, portanto, não colocaria em risco o bem jurídico tutelado. Requer a fixação de pena mínima e o direito de apelar em liberdade.

DECIDO.

1 -) SÍNTESE PROBATÓRIA

1.1 -) Das provas da materialidade.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de exibição e apreensão do inquérito policial (págs. 37/38), laudo químico-toxicológico definitivo (págs. 120/122) e pelos laudos periciais de páginas 123/128 sobre a arma de fogo e as munições, além do laudo de pgs. 129/134 sobre o simulacro de arma de fogo.

Houve, pois, modificação do mundo naturalístico pela conduta, restando atendido o princípio da materialização do fato.

2.2 -) Das provas da autoria.

Welther Vaz Martins informa que tinham recebido denúncia de tráfico de drogas na residência dos réus. Deslocaram-se até lá e montaram campana nas proximidades da residência. O réu Amélio (pai) ficava na frente da residência e conversava com pessoas. Ele entrou na casa, pegou algo e entregou. Os usuários saíram, mas dispensaram 2 pinos de cocaína. Foram para a sala e encontraram 8 porções de cocaína. O filho de Amélio estava dormindo, mas entraram no quarto deles e perguntaram sobre mais drogas e o filho negou. No quarto de Amélio pai havia 126 porções de cocaína, além de outra porção não fracionada da mesma droga, as munições e um revólver. Não é normal encontrar tamanha quantidade de munição. As buscas continuaram e encontraram R\$ 10.000,00 em espécie. O dinheiro foi apreendido. O filho assumiu a posse das 8 porções que estavam na estante. O pai negou que houvesse mais drogas, mas o restante das drogas estavam no quarto do Amélio (pai). A grande quantia estava no quarto do Sr. Amélio. Havia denúncias anteriores de 20 a 30 dias, mas não foi possível apurar imediatamente. Na primeira oportunidade constatarem a traficância. Sobre o dinheiro o Sr. Amélio disse que lhe pertencia e não era de origem ilícita. Os pinos dispensados são idênticos àqueles encontrados no interior da residência dos réus. Era um dia nublado. No momento da abordagem não sabe se estava chovendo, mas no desenrolar da ocorrência parece que estava chovendo. Estava de 20 a 40 metros da residência. É a distância que normalmente

ficam para perceber a movimentação. O atendimento ao usuário foi de fora do imóvel e o Amélio (pai) estava na presença de outras pessoas. Tentaram abordar o usuário, mas ele correu e não foi possível. Ele dispensou algo e perceberam que eram as porções de cocaína. Perceberam porque ele fez um gesto para trás, típico de quando alguém joga algo correndo. Em Rio Pardo existem pinos maiores no que se refere ao tamanho. Não sabe o valor dos pinos que foram apreendidos. Há pinos de valores variados e os eppendorfs são da mesma cor. Amélio Filho assumiu a droga que estava na sala, mas depois ambos negaram que houvesse outras drogas ou objetos ilícitos na casa. Depois o réu Amélio filho também assumiu a propriedade das outras drogas.

Cesar Augusto Seridonio relata que na época dos fatos receberam delação anônima dando conta de que pai e filho estavam traficando drogas em São José do Rio Pardo. Pelo acúmulo de trabalho não foi possível ir antes ao local. Mas, no dia dos fatos, foram ao local e observaram um usuário fazendo contato com o Amélio pai que entregou algo para ele. O usuário empreendeu fuga e dispensou 2 pinos de cocaína. Foram na residência e localizaram 8 ou 10 pinos de cocaína na estante da sala. O filho estava dormindo. Foi chamado e vistoriaram o quarto dele. Ele confirmou que a droga da estante era de sua propriedade, mas disse que não havia mais drogas naquele local. Encontraram uma bolsa no quarto do Amélio pai com grande quantidade de pinos de cocaína, além de arma e munições. Acharam também droga a granel e um simulacro de arma de fogo. O simulacro poderia ser produto de um roubo praticado em Rio Pardo que ainda estava em investigação. Encontraram também R\$ 10.000,00 em dinheiro. Amélio Filho informou que a droga que estava na sala era dele e que não teria mais nenhuma droga na residência. No quarto do Amélio pai, percebeu que ele estava muito nervoso, mas acharam a bolsa com as drogas e arma. Aí o filho assumiu também a droga dentro do quarto do pai. O pai negava, mas estava muito nervoso, como se soubesse que a droga estava lá escondida no quarto dele lá. Estava nublado e no momento da abordagem acredita que estava choviscando. Estavam de 30 a 40 metros do local dos fatos. Tentou fazer a abordagem do usuário que empreendeu fuga e chegou a dispensar 2 pinos de cocaína. O depoente viu quando ele dispensou. Os eppendorfs em Rio Pardo são diversos. Os pinos dele eram maiores, acredita que no valor de R\$ 25,00. Os pinos encontrados com o usuário eram iguais aos pinos apreendidos na sala e no quarto de Amélio Pai. A princípio, Amélio filho confirmou que as drogas na estante eram dele e disse que não havia mais drogas na residência. Quando encontrada a sacola no quarto do Amélio pai, aí o Amélio filho também assumiu a propriedade das drogas, armas e munições.

José Carlos Marques não estava no local, estava em Campinas. Conhece ele há uns 35 anos e mora a 3 casas dele. O Amélio pai é caminhoneiro, trabalhou na Nestlé e viveu a vida normalmente. Nunca percebeu movimentação estranha na casa porque saía cedo e voltava à noite. Nunca notou o movimento. Com relação ao Amélio Filho não tinha amizade igual tinha com o pai. Aparentemente ele era tranquilo. Não sabe se eles tinham problemas com vizinhos ou ameaças de qualquer pessoa. Nunca tinha visto armas lá.

Clóvis Fernando de Faria estava lá no dia e assim que os policiais chegaram deram voz de prisão para o Sr. Amélio. Tinha acabado de chegar e viu a polícia entrando na casa. Não viu droga, nem arma, mas a polícia mandou o depoente ir embora. Então não viu mais nada. É vizinho deles há 46 anos. Foi nascido e criado ali. Nunca percebeu movimentação na casa. Trabalha fora e chega 19:30 - 20:00. Frequenta a casa deles. Já tomou cerveja com o outro filho do Amélio. Conhece o Amélio Filho, mas não fica junto com ele. O Amélio pai é aposentado, já teve caminhão e aposentou. Ele fazia frete para o cunhado do depoente que tinha cerâmica. Nunca ouviu falar que eles tivessem problemas com vizinhos ou pessoas ameaçando. Quando a polícia chegou estava fora da casa apenas o Amélio pai. A polícia mandou ele entrar. Quando a polícia chegou estava o outro filho dele com o depoente.

Amélio Ribeiro Filho na cadeia está normal. Nunca foi preso ou processado. Está com 30 anos. Era ajudante do seu pai e ajudava também em serviço de pintura e seu irmão na funilaria. Estudou até o primeiro ano. Usa cocaína e fuma maconha também. Ouviu o que os policiais disseram. É um injustiça o que fizeram com o seu pai. Pelo vício da droga, colocou a mochila no quarto do seu pai que não sabia de nada. Na idade dele ele não ver. Colocou no quarto do seu pai por questão de segurança. Chorou muito por causa dele. A arma e munição também lhe pertence. Pegou essas coisas de errado e fez tudo isso. A pessoa que estava conversando com seu pai lá fora poderia ser amigo do depoente. Foi um rapaz lá e não sabe se o mesmo da hora da abordagem. O depoente tinha acabado de acordar. Seu pai disse que tinha um rapaz lhe chamando. Antes tinha deixado 2 eppendorfs de cocaína com um rapaz. A polícia mandou o rapaz entrar porque achou que era amigo do depoente. O rapaz que correu é outro, mas deve ser o mesmo que tinha pegado a droga com o depoente. Confessa e isenta seu pai de toda a situação. Reafirma que seu pai é inocente e o depoente é o culpado de tudo. O seu pai só chamou o cara para entrar na casa.

Amélio Ribeiro, 73 anos, está sendo bem tratado na prisão. Trabalhou na Saverba e na Nestlé. Aposentou-se com 45 anos e trabalhou um caminhão até o ano passado, mas vendeu o caminhão. Estava treinando os filhos, mas ficou ruim para trabalhar. Falou para os filhos arrumarem trabalho e vendeu o caminhão. Trabalhava em casa, ajudando a esposa. Estudou até a 7ª série e não teve condições mais. Nunca traficou e nunca gostou de drogas. Sempre foi direito e honesto e nunca deixou as coisas para trás. A polícia chegou lá e deu uma geral. Não era do seu conhecimento e ficou arrasado, sem saber o que fazer. Não era coisa sua, era do seu filho. Tentou ajudar ele, colocou ele para morar dentro da casa do depoente. Teve que vender o caminhão e ficou passando aperto. Não deve nada e não sabia que existia essas coisas na sua casa. Tem muitos amigos em São José. Não atendeu ninguém na porta. Falou apenas com seu filho, mas nem lá fora saiu. Ia para Mococa, com seu filho mais velho. Não sabe quem colocou essa bolsa nos seus aposentos. Não viu eles abrindo a bolsa porque colocaram o depoente na cozinha da casa. Não se lembra se seu filho deu algum esclarecimento, não. A única coisa importante que tem para dizer é que está mal de saúde, tem prótese na perna e problema de coluna. Precisa sair da prisão porque tem vários problemas de saúde. Está sendo atendido na cadeia, mas precisa sair para resolver problemas com sua esposa e não tem como fazer nada. O que está ruim é dormir porque tem problema de bexiga e levanta a noite inteira. Não tem visão boa, operou uma vista e precisava fazer a outra operação. Não autorizou a entrada da polícia. Eles chegaram e invadiram a casa. Eles não conseguiram ver nada a distância.

3-) DA ANÁLISE CRÍTICA E DO DIREITO APLICÁVEL:

Ab initio, é preciso consignar a validade do testemunho policial, pois “goza de presunção de credibilidade”.

Quanto às falas dessas testemunhas, à guisa de ter o agente atuado no feito, tenho por oportuno destacar a sua aproveitabilidade, tanto como a de qualquer pessoa. É que o depoimento do policial, em razão de sua condição de agente da Administração Pública, presume-se verdadeiro e merece crédito, mormente porque se mostra firme, coeso e em consonância com o conjunto probatório dos autos. Tal presunção, obviamente, admitiria prova em contrário, que, entretanto, não foi produzida pela defesa.

A credibilidade do depoimento de policiais tem tanta força quanto a de outros indivíduos. O fato de que cabe a eles a atribuição de prevenir e reprimir o crime não tem o condão de invalidar, de per si, a prova decorrente de seus testemunhos.

Por mero preconceito ou suspeita infundada, não pode o Estado-Juiz entender tais depoimentos imprestáveis para lastrear sentença condenatória. O depoimento policial tem plena força probatória, se não houver nenhuma razão plausível, cabalmente comprovada nos autos, para se lhe retirar a credibilidade.

Preceitua o artigo 202 do CPP que “toda pessoa pode ser testemunha”, logo, é indiscutível que os policiais, sejam eles os autores da prisão do réu ou não, podem testemunhar, sob compromisso de dizer a verdade e, assim, sujeitos às penas do crime de falso testemunho. Além disso, desconsiderar a validade probatória de um depoimento levando-se em conta, apenas, a profissão de uma pessoa (por exemplo: policial militar ou civil), nada mais é do que tratamento violador do princípio da igualdade, postura essa temerária ao direito.

O escólio pretoriano bem elucida a questão:

“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstra – tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos” (STF – 1ª Turma – HC 74.608-0/SP – Rel. Min. Celso de Mello – DJU de 11.04.97, pág. 12.189).

“A SIMPLES CONDIÇÃO DE POLICIAL NÃO TORNA A TESTEMUNHA IMPEDIDA OU SUSPEITA – STF, RTJ 68/64 E 168/199” (Damásio E. de Jesus, Código de Processo Penal Anotado, Saraiva, 19ª Edição, 2002, p. 176 e 182).

Ainda nesse sentido:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações. Tratando-se de sentença condenatória escorada não apenas nos depoimentos prestados em Juízo pelos policiais, como também nos esclarecimentos feitos pelas próprias testemunhas da defesa, não é possível rever todo o acervo fático-probatório do feito criminal para perquirir se as provas a que se referiu o magistrado de primeira instância são ou não suficientes para produzir uma condenação. (...) Ordem denegada.” (HC 87662, Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma, julgado em 05/09/2006, DJ 16-02-2007 PP-00048 EMENT VOL-02264-02 PP-00280 LEXSTF v. 29, n. 339, 2007, p. 417-421). (grifos meus)

Outrossim, é de se ter em conta que se tratando de tráfico de entorpecentes, opera-se a “lei do silêncio”, extremamente difícil arrolar testemunhas dispostas a testemunhar contra traficantes.

A perfeita identidade entre as versões, tal como se vê em solo policial e depois em Juízo, é reconhecida pela jurisprudência como fator hábil a dar validade à prova testemunhal policial.

No que se refere à validade da denúncia anônima, apesar de sua precariedade, ela deve ser objeto de investigação policial, em face da possibilidade de serem

apurados elementos suficientes ao oferecimento de denúncia ou representação em caso de infratores.

Considerando a enorme incerteza em torno de suas informações, recomenda-se especial cautela no procedimento, visando preservar o acusado de desnecessário constrangimento.

Mesmo que a Constituição vede o anonimato na manifestação do pensamento (art. 5º, IV), não há falar em rejeitar-se, de plano, comunicação de delito com procedência desconhecida, porque se poderia estar coartando a pretensão punitiva do Estado em circunstância própria ao desenvolvimento de ação penal ou procedimento para apuração de ato infracional.

A jurisprudência tem chancelado a denúncia anônima como instrumento hábil a desencadear a persecutio criminis. O Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais apresenta escólio singular:

“A denúncia anônima não é ato ilícito, sendo incapaz de viciar a investigação criminal, encontrando amplo fundamento constitucional, por visar a preservação da ordem pública e garantir, paralelamente, a incolumidade dos denunciante, ambos objetivos fundamentais de todo o sistema da segurança pública previsto na Constituição Federal (art. 144, caput). (Apelação Criminal nº 1.0024.07.765340-0/001(1), 5ª Câmara Criminal do TJMG, Rel. Adilson Lamounier. j. 02.09.2008, maioria, Publ. 15.09.2008).”

Em obra dedicada ao tema “A busca da verdade no processo penal” Marco Antônio de Barros conclui:

“Existem dois entendimentos sustentados na literatura jurídica. Uma corrente entende que o anonimato não se mantém ao ser confrontado com a norma constitucional. E a outra corrente justifica a sua validade, argumentando que o anonimato dá ensejo a uma investigação preliminar, sendo que eventual indiciamento e acusação posterior sempre ficarão condicionados ao arrimo de provas colhidas no curso das investigações. Desde que a investigação policial provocada pelo disque-denúncia seja efetivamente desenvolvida com esteio absolutamente regular, entendemos que não há parâmetro legal para impugnar as provas pertinentes à ocorrência de ilícito penal originariamente noticiado à Polícia Judiciária por este modo.”

O que seria inadmissível é a condenação dos denunciados apenas com base na delação não-identificada, ou seja, na hipótese de nada mais existir estaria vedado ao Estado-Juiz fiar-se apenas na notícia anônima para chancelar condenação.

No entanto, nada impede que haja atuação policial desencadeada a partir de informação não-identificada. E, no presente caso, a atuação policial conseguiu reunir prova da materialidade de crime contra a saúde pública e identificou a autoria de forma evidente, pois o réu Amélio Ribeiro foi visualizado no local entregando drogas para um usuário e na sequência houve efetivamente apreensão de drogas, arma de fogo e munições.

Com relação à suposta ilegalidade da busca domiciliar impõe-se desde logo registrar que o Supremo Tribunal Federal (STF), anulou parte de decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que impôs aos órgãos de segurança pública de todo o país a obrigação de registrar, em áudio e vídeo, o ingresso no domicílio de suspeito, como forma de comprovar o consentimento do morador. A decisão foi proferida no Recurso Extraordinário (RE) 1342077, interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo (MP-SP).

Além disso, no julgamento do RE 603616, com repercussão geral, foi firmada tese objeto do TEMA 280 com maioria dos votos segundo a qual “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”.

Com isso, o Plenário do STF passa a exigir justa causa para que a polícia possa ingressar em residências, controlável “a posteriori”.

No presente caso, além das denúncias anônimas levadas ao conhecimento de Delegacia localizada em outra comarca – Seccional de Casa Branca, tem-se que os policiais civis contiveram-se nas margens da legalidade realizando prévia campana e apenas após visualizarem ato típico de mercancia de drogas resolveram agir.

Primeiro encontraram a droga dispensada pelo usuário. Apenas no momento seguinte ingressaram no domicílio. Destarte, nenhuma ilegalidade pode ser pronunciada, sob pena de coartar-se definitivamente a ação policial, convolvando a garantia da inviolabilidade domiciliar em blindagem para a prática de crimes, o que certamente desvirtua o escopo da Constituição Federal ao anunciar que os objetivos da República são a construção de uma sociedade livre, justa e solidária (artigo 3º, inciso I, CRFB/88).

Não há justiça no estímulo ao crime escamoteado na retórica de um hipergarantismo.

Zygmunt Bauman na obra "Tempos líquidos" nos lembra que "Se você quer a paz, cuide da justiça", advertia a sabedoria antiga – e, diferentemente do conhecimento, a sabedoria não envelhece. Atualmente, a ausência de justiça está bloqueando o caminho para a paz, tal como o fazia há dois milênios. Isso não mudou."

A defesa sustenta que a prova é duvidosa em relação ao réu Amélio Ribeiro (pai). O Juízo diverge.

Com efeito, a dúvida capaz de favorecer o réu deveria estar sustentada em contraprovas e não meramente a partir de argumentações, sob pena de contemplar-se indevidamente a subjetividade e o "decisionismo".

Nesse sentido, os ensinamentos de FRAMARINO DEI MALATESTA, o qual afirma que “o princípio ontológico coloca o ônus de prova a cargo da acusação, quando considera as duas asserções contrárias, do acusador e acusado, antes da produção de provas. Mas, desde o momento em que o acusador reuniu as suas provas para sustentar a sua asserção, se o acusado, em contradição à asserção do acusador, emite simples asserção contrária, não faz mais que contrapor uma asserção não provada a uma provada e como esta tem direito de ser tomada como verdadeira de preferência a não provada, sendo a presunção da verdade, neste segundo momento, a favor do acusador, a obrigação da prova incumbe ao acusado” (A Lógica das Provas em Matéria Criminal, Campinas: Conan 1995 v. I p. 45-146 – destaque do Juízo).

A verdade processual obtida vem no sentido de que as acusações ministeriais estão evidenciadas em sólidos depoimentos dos policiais civis que primeiro viram o réu Amélio (pai) entregando algo a um terceiro. Tal pessoa, em fuga, dispensou eppendorfs de cocaína. No interior da residência e mais precisamente no interior do quarto de Amélio (pai) foi encontrada grande quantidade de drogas e munição. O próprio corréu – Amélio (filho) confirma que a bolsa estava escondida no quarto do seu pai, embora alegue que este de nada soubesse.

José Carlos Marques nem estava no local, ao passo que Clóvis Fernando de Faria

teria presenciado os eventos apenas à distância. Ambos atestam a boa conduta de Amélio pai, o que será avaliado no âmbito das circunstâncias do art. 59 do Código Penal. Porém, os depoimentos não produzem reflexos sobre a conclusão extraída objetivamente da prova acusatória que é contundente e direta em incriminar ambos os réus.

A situação de Amélio Filho conta com a resignação da defesa no que tange ao tráfico de drogas, pois limita-se a indicar a confissão.

A tese de crime impossível para a acusação referente ao crime previsto na Lei 10.826/2003 não encontra abrigo.

A arma de fogo - revolver usado, da marca Rossi, numeração J103284, calibre nominal .38 foi apreendida juntamente com as munições do mesmo calibre - item "a" do laudo de pgs. 25.

A conduta foi praticada sob a égide da lei 10.826/2003 conhecida vulgarmente como "Estatuto do Desarmamento" cujo artigo 12 tem a seguinte redação:

Art. 12. Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa:

Pena detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.

O crime de posse ilegal de arma de uso permitido, tipificado no artigo 12 da Lei nº 10.826/2003, é de perigo abstrato - ou de mera conduta - e visa proteger a segurança jurídica e a paz social. Observe-se o entendimento do E. STF:

STF-) AGRADO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS INTERPOSTOS NO STJ. INVIABILIDADE DE REEXAME NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. POSSE DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI 10.826/2003). ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal, em sede de habeas corpus, proceder ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência exclusiva do Superior Tribunal de Justiça (CF, art. 105, III), salvo em hipótese de flagrante ilegalidade, o que não se verifica na espécie. Precedentes. 2. Ainda que superado esse óbice, a questão relativa à ausência de justa causa para a condenação foi assim examinada, com suficiência, pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo que não há constrangimento ilegal a ser sanado. 3. Ademais, o tipo penal do art. 12 da Lei nº 10.826/03, ao prever as condutas de possuir ou manter, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, contempla crime de mera conduta, sendo suficiente a ação de possuir ilegalmente a munição. Objetiva-se, assim, antecipar a punição de fatos que apresentam potencial lesivo à população, prevenindo a prática de crimes. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (Ag. Reg. no Habeas Corpus nº 127652/SP, 2ª Turma do STF, Rel. Teori Zavascki. j. 02.06.2015, unânime, DJe 17.06.2015). (negrito acrescentado)

PROCESSUAL PENAL. AGRADO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE LESIVIDADE. CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. APLICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a "posse de arma de fogo de uso restrito, de seus acessórios ou de munições constitui crime de mera conduta e de perigo abstrato cujo objeto jurídico tutelado compreende a segurança coletiva e incolumidade pública" (RHC 128. 281, Rel. Min. Teori Zavascki). 2. Situação concreta em que o agravante foi condenado pelo delito do art. 12 da Lei nº 10.826/2003 - posse de 04 (quatro) munições calibre 22 (vinte e dois) - e também pelo delito do art. 155 do Código Penal (furto de uma motocicleta), o que repercute negativamente na avaliação quanto à periculosidade social da ação e ao grau de reprovabilidade do comportamento do agente. A impossibilitar a aplicação do

princípio da insignificância. 3. Agravo regimental desprovido. (Ag. Reg. no Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 151583/MS, 1ª Turma do STF, Rel. Roberto Barroso. j. 24.05.2019, maioria, DJe 05.06.2019).

Irrelevante, portanto, o argumento defensivo de que a arma estava desmuniada. Para configuração do crime, basta a posse da arma, sem autorização legal ou regulamentar. Reitere-se que, no caso concreto, havia munição disponível ao alcance dos réus.

Presente a tipicidade delitiva na forma imputada na denúncia e não havendo justificativas ou dirimentes capazes de afastar a antijuridicidade das condutas e culpabilidade dos réus, a condenação é medida necessária para a concretização dos escopos de prevenção geral positiva e prevenção especial colimados pelo sistema punitivo, além de restabelecer o princípio da prevalência do Direito e atestar a vigência da norma penal violada.

4 -) DISPOSITIVO E DOSIMETRIA DA PENA.

Ex positis, JULGO PROCEDENTE a denúncia de págs. 158/161, para CONDENAR AMÉLIO RIBEIRO FILHO e AMÉLIO RIBEIRO pela prática do crime capitulado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 e no artigo 12, "caput", da Lei nº 10.826/2003, na forma do artigo 69 do Código Penal, passando a dosar-lhe a pena, nos termos do artigo 68 do Código Penal e artigo 42 da Lei de Drogas.

- EM RELAÇÃO AO RÉU AMÉLIO RIBEIRO FILHO - CRIME DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006:

Analisadas as diretrizes do artigo 59 do Código Penal e 42 da Lei 11.343/2006, observa-se que o modus operandi não recomenda que seja acentuada a pena, pois a culpabilidade é normal à espécie.

Poucos elementos foram coletados acerca de sua conduta social e personalidade, razão pela qual não influenciam negativamente a dosimetria. Além disso, deixo transparecer que tais circunstâncias judiciais se analisadas em detrimento do réu evidenciam acolhimento do "direito penal de autor", fenômeno indesejável e antigarantista que não conta com o aval deste Juízo.

Cabe ressaltar, ainda, a exasperação também não é medida a se impor, neste caso, em relação à natureza das drogas. Crack, cocaína e maconha são entorpecentes considerados "comuns" encontrados em qualquer cidade e apreendidos com frequência diária em São José do Rio Pardo.

A interpretação da Lei Penal exige que este Juízo considere que apenas substâncias excepcionais como ópio, LSD, ecstasy, heroína, poderiam justificar a majoração da pena com base na natureza do entorpecente.

No entanto, o critério "quantidade" compreende duas variáveis:

1ª O peso, massa, das substâncias propriamente ditas (neste caso não é suficiente para gerar acréscimo na pena, pois a apreensão foi de cerca de 55,36 gramas - conforme massa líquida, verificada em laudo pericial de pág. 121).

2ª A diversidade, variedade das substâncias, pois em "quantidade" de drogas podemos ter pequenas ou grandes porções de 1,2,3 ou mais drogas diferentes.

Analisando os itens o Juízo encontra campo para ligeiro acréscimo, uma vez que a quantidade apreendida está acima dos padrões das apreensões normais e corriqueiras

nesta comarca.

O motivo do delito se constitui pela vontade de locupletar-se com a venda de entorpecente o que já está albergado no próprio tipo legal.

As circunstâncias do delito não destoam daquelas em que ocorrem crimes desta natureza, ao passo que não há elementos para aferir se as consequências foram graves.

O réu é primário, pois não houve qualquer condenação nos registros que constam nas pgs. 52/54.

À luz dessas circunstâncias é que fixo a pena-base para o crime capitulado no artigo 33, caput da Lei 11.343/2006 1/6 acima do mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos e 10(dez) meses de reclusão e 583 dias-multa.

Amélio Filho é confesso. Portanto, a pena deve ser atenuada e reconduzida ao mínimo legal de 5(cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Não faz jus à causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, pois como visto, também foi condenado pela prática do crime previsto no art. 12 da Lei 10.826/2003, de modo que vinha dedicando-se a atividades criminosas.

Foram apreendidos mais 97 microtubos vazios, além de R\$ 10.200,00 em espécie, o que demonstra não tratar-se de traficante iniciante cujo perfil deva receber a benesse representada pela referida minorante.

Nos termos constantes às pgs. 97 "Além disso, a quantidade de drogas encontradas, arma de fogo, munições, simulacro de arma de fogo, bem como as importâncias em dinheiro, demonstram que os indiciados se dedicam a atividades criminosas e possuem certo know-how no comércio de entorpecentes, mantendo estrutura incompatível com a de um mero usuário ou traficantes incipientes, uma vez que estavam na posse até mesmo de arma de fogo e munições em quantidade expressiva." (com negrito no original).

O regime inicial é o FECHADO, pois mantida a hediondez da conduta. Além disso, observa-se que o réu também foi condenado por outro crime nesta mesma sentença e suas ações vinham conturbando a ordem pública a ponto de denúncias serem direcionadas à DIG de Casa Branca acerca da traficância desempenhada no imóvel.

O regime fechado é o único capaz de desfazer a "teia criminosa" na qual estava envolvido, coligado a traficantes de maior envergadura, fornecedores de arma e munições, além de sua própria "clientela".

Qualquer regime que lhe permita o contato precoce com o meio aberto viabilizará retomada prematura de laços com tal submundo, desvirtuando completamente o escopo de ressocialização.

Pelo crime do art. 12 da Lei 10.826/2003, além da arma foram apreendidas diversas munições. Assim, a pena base deve situar-se em 1(um) ano e 6(seis) meses de detenção e 15 dias-multa, afigurando-se insuficiente o acréscimo de apenas 1/6 à reprimenda quando considera-se a quantidade de munições e o fato de que a posse apenas delas poderia configurar crime autônomo.

Havendo campo para que a pena flutue entre 1 a 3 anos, não se afigura demasiado o acréscimo de 6(seis) meses à pena base pelos fundamentos supra.

Pela confissão, desconto 1/6 na reprimenda, que fica no patamar de 1(ano) e 3(três) meses de detenção e 12 dias-multa, a qual torno em definitiva à míngua de causas

gerais ou especiais de diminuição ou aumento de pena.

Delito apenado com mera detenção. Reprimenda a ser expiada em regime SEMIABERTO.

Não permito que o réu apele em liberdade, ficando mantidos os fundamentos de sua custódia cautelar externados nas pgs. 60/69. Além do regime fechado imposto pela traficância, tem-se que a prisão cautelar é necessária para desarticular o esquema de tráfico de drogas no qual o réu estava imerso, retirando-o do "mercado" ou do "ramo de comércio" sem possibilidade de retorno em breve espaço de tempo, sob pena de ineficácia da intervenção penal estatal no caso concreto.

Recomende-se no estabelecimento prisional em que se encontra, ficando substituído o título da prisão pela presente sentença penal condenatória recorrível.

- EM RELAÇÃO AO RÉU AMÉLIO RIBEIRO (pai)

Reitero a análise feita em relação ao corréu Amélio Filho para fixar a pena base em 5(cinco) anos e 10(dez) meses de reclusão e 583(quinhetos e oitenta e três dias-multa) na primeira fase.

Registre-se que este réu também é primário.

Na segunda etapa, foi bem lembrada pela defesa a atenuante do inciso I do art. 65 do Código Penal, de modo que a pena fica reconduzida ao patamar de 5(cinco) anos de reclusão e 500(quinhetos) dias-multa.

A exemplo do seu filho, Amélio Ribeiro vinha se dedicando a atividades criminosas coadjuvando Amélio Ribeiro Filho na prática do tráfico de drogas, guardando as substâncias entorpecentes em seu próprio quarto. Também foi condenado pela posse em coautoria das armas e munições, o que demonstra claramente que vinha se dedicando a atividades criminosas clandestinamente nesta cidade, auxiliando o filho.

Não faz jus, portanto, à minorante do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, ficando a pena definitiva em 5(cinco) anos de reclusão e 500(quinhetos) dias-multa.

O regime inicial é igualmente o FECHADO, pelos mesmos motivos expostos na fundamentação em relação ao réu Amélio Filho.

Pelo crime de posse irregular de armas e munições, imponho-lhe a mesma pena do corréu, pois embora não tenha confessado também beneficia-se pela atenuante da idade superior a 70(setenta) anos.

A pena deste delito fica em 1(ano) e 3(três) meses de detenção e 12 dias-multa, a qual torno em definitiva à míngua de causas gerais ou especiais de diminuição ou aumento de pena.

O regime inicial desta reprimenda é o SEMIABERTO.

Inviável a substituição da pena para qualquer dos réus, pois a reprimenda ultrapassou quatro anos.

Em relação a Amélio Ribeiro (pai), considerando as peculiaridades de sua situação pessoal, dentre elas a idade avançada, o estado de saúde (receituário de pgs. 97/99 e declarações prestadas no interrogatório), o histórico de vida apresentado pelas testemunhas de defesa e especialmente o fato de que seu filho será mantido encarcerado preventivamente, tem-se que o esquema de dispersão de entorpecentes permanecerá rompido.

Como visto, Amélio Ribeiro Filho era o principal articulador dos crimes, apresentando-se como responsável pelas drogas, arma e munições. O genitor apenas o coadjuvava nas atividades ilícitas desempenhadas naquela residência e não é crível que em liberdade irá, por seus próprios meios e sem a audácia e ímpeto próprios da juventude, retomar as atividades criminosas com risco de novo decreto de prisão e nova condenação.

Sendo assim, possível substituir a prisão preventiva de Amélio Ribeiro por cautelares diversas da prisão a fim de que possa aguardar o julgamento de eventual recurso sem as amarras do cárcere. A medida prestigia o acesso ao duplo grau de jurisdição deste réu que, ao contrário de Amélio Ribeiro Filho, não é confesso e também reserva à prisão preventiva seu caráter excepcional e instrumental.

SUBSTITUO a prisão preventiva de Amélio Ribeiro por obrigação de comparecimento mensal em Juízo para justificar suas atividades; recolhimento domiciliar noturno entre as 20:00 e 06:00 horas; proibição de ausentar-se da comarca sem autorização judicial, além da obrigação de manter atualizado seu endereço para fins de intimações.

Expeça-se alvará de soltura com as cláusulas supra.

CONDENO os réus ao pagamento das custas processuais que fixo em 100 UFESP's. Ressalte-se que o réu está patrocinado por advogada dativa e relatou que não possui emprego. Assim, defiro-lhe os benefícios da assistência judiciária.

Saliento que "A condição de beneficiário da Justiça Gratuita não isenta o condenado do pagamento das custas. Eventual isenção poderá ser avaliada à época da execução da sentença condenatória, quando serão apreciadas as reais condições quanto ao estado de pobreza do réu e à possibilidade do pagamento das custas processuais sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família. Precedentes. Recurso desprovido, nos termos do voto do relator" (STJ, REsp 343.689/MG, Rel. Min. Gilson Dipp, T5, DJ 22.04.03, p. 253).

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão, adotem-se as seguintes providências:

Expeça-se mandado de prisão para o réu Amélio Ribeiro observando os regimes fixados. Com o cumprimento o réu deverá ser apresentado em regular audiência de custódia.

Proceda-se ao recolhimento dos valores atribuído a título de pena pecuniária, em conformidade com o disposto no artigo 686 do Código de Processo Penal; Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação, com sua devida identificação, acompanhada de fotocópia desta decisão, para cumprimento do disposto nos artigos 71, §2º do Código Eleitoral c/c inciso III do artigo 15 da Constituição da República;

Oficie-se ao órgão responsável pelo cadastro de antecedentes criminais deste Estado para as anotações necessárias;

Se patrocinado por advogado dativo, honorários na forma do convênio OAB-DPE.

Decreto o perdimento dos valores apreendidos, pois à míngua de comprovação de origem lícita estão claramente vinculados à mercancia de entorpecentes ilegal desempenhada pelos réus, um deles confesso. O empréstimo de pgs. 172/173 teria sido contraído há seis meses antes da prisão, de modo que não serve de lastro para o numerário apreendido. Aliás, foram apreendidos mais de R\$ 10.000,00 e o empréstimo seria de apenas R\$ 4.710,84. Os demais documentos são igualmente insuficientes para dar lastro legítimo ao valor. Ao contrário, demonstram situação financeira incompatível com a possibilidade de manter-se em espécie, no próprio domicílio, a quantia apreendida.

Nos termos do art. 72 da Lei de Drogas, proceda-se à destruição do entorpecente mantido para fins de contraprova.

Publique-se,
Intime-se e
Cumpra-se.

Sao Jose do Rio Pardo, 19 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA